

刑事訴訟法第 321 条第 1 項の書面に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 公判廷に証人として出廷した者が、捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述をしたとき、その者の検察官の面前における供述を録取した書面については、その検察官の面前における供述が特に信用すべき状況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められない。

イ. 刑事訴訟法第 321 条第 1 項第 1 号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」は、当該事件に関して作成されたものに限られるから、他の事件の公判廷における証人の供述を録取したものは含まれない。

ウ. 刑事訴訟法第 321 条第 1 項の「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」とは、供述不能の制限的な事由ではなく、例示的な事由であるから、証人が、公判期日に証言拒絶権を行使して証言を拒んだときも、これに該当する。

エ. 裁判所が証人尋問の決定をした外国人について、証人尋問の実施前に退去強制が行われた場合、その者の検察官に対する供述調書を刑事訴訟法第 321 条第 1 項第 2 号前段に基づいて証拠とすることは、許容されないことがある。

オ. 被告人には黙秘権の保障があり、かつ、宣誓及び偽証罪の制裁を欠くのであるから、乙を被告人とする贈賄被告事件の公判調書中、被告人としての乙の供述を録取した部分は、甲を被告人とする収賄被告事件において、刑事訴訟法第 321 条第 1 項第 1 号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」には該当しない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

321 条 1 項 2 号後段ただし書。検察官の面前における供述を録取した書面について、供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反する供述をしたときは、公判準備若しくは公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況（相対的特信情況）があれば、証拠能力が認められる。したがって、本記述は、検察官の面前における供述が特に信用すべき情況、すなわち絶対的特信情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められないとしている点で、誤っている。

イ 誤っている

最決昭 29.11.11。判例は、「刑事訴訟法 321 条 1 項 1 号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わない」としている。したがって、本記述は、当該事件に関して作成されたものに限られるとしている点で、誤っている。

ウ 正しい

最大判昭 27.4.9。判例は、321 条 1 項 2 号の「供述者が……供述することができないとき」の意義が問題となった事案において、「『供述者が……供述することができないとき』としてその事由を掲記しているのは、もとよりその供述者を裁判所において証人として尋問することを妨ぐべき障碍事由を示したものに外ならないのであるから、これと同様又はそれ以上の事由の存する場合において同条所定の書面に証拠能力を認めることを妨ぐるものではない」として、例示列举であるとしている。そして、「されば……証人として喚問されながらその証言を拒絶した場合にあっては、検察官の面前における同人の供述につき被告人に反対尋問の機会を与え得ないことは右規定にいわゆる供述者の死亡した場合と何等選ぶところはないのである」として、証人の証言拒絶が供述不能にあたるとしている。その理由として、判例は、「証言拒絶の場合においては、一旦証言を拒絶しても爾後その決意を翻して任意証言をする場合が絶無とはいえないのであって、この点においては供述者死亡の場合とは必ずしも事情を同じくするものではないが、現にその証言を拒絶している限りにおいては被告人に反対尋問の機会を与え得ないことは全く同様であり、むしろ同条項にいわゆる供述者の国外にある場合に比すれば一層強き意味において、その供述を得ることができないものといわなければならない。」としている。さらに、判例は、1 号の「供述者が……供述することができないとき」につき例示列举であるとして、証言拒絶が供述不能にあたるとしている（最決昭 44.12.4）。また、判例は、3 号についても例示列举であるとして、証言拒絶が供述不能にあたるとしている（最決昭 29.7.29）。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

最判平 7.6.20（百選 80 事件）。判例は、退去強制によって出国した者の検察官に対する供述調書の証拠能力について、まず、「右規定が同法 320 条の伝聞証拠禁止の例外を定めたものであり、憲法 37 条 2 項が被告人に証人審問権を保障している趣旨にもかんがみると、検察官面前調書が作成され証拠請求されるに至った事情や、供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、その検察官面前調書を常に右規定により証拠能力があるものとして事実認定の証拠とすることができるとすることには疑問の余地がある」としている。その上で、判例は、「検察官において当該外国人がいずれ国外に退去させられ公判準備又は公判期日に供述することができなくなることを認識しながら殊更そのような事態を利用しようとした場合はもちろん、裁判官又は裁判所が当該外国人について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合など、当該外国人の検察官面前調書

を証拠請求することが手続的正義の観点から公正さを欠くと認められるときは、これを事実認定の証拠とすることが許容されないこともあり得る」としている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

最決昭 57.12.17 (百選 A36 事件)。判例は、「刑事訴訟法 321 条 1 項 1 号の『裁判官の面前における供述を録取した書面』には、被告人以外の者に対する事件の公判調書中同人の被告人としての供述を録取した部分を含むと解するのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、1 号書面は宣誓証言に限るという法律上の根拠は必ずしもなく、またそのように解すると 3 号書面としてしか扱えず、およそ宣誓が考えられない検察官の面前での供述録取書よりも厳格な要件を課すことになり、不合理であるということ、また、黙秘権の保障、宣誓及び偽証罪の制裁を欠くことは、証拠能力にとって致命的なものではなく、個々具体的な供述につき交互尋問類似の方式により信用性の吟味をすることで足りるということを挙げている。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。

